

1502232-08.2021.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/07/2022
... Em caso análogo:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá-SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502232-08.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502232-08.2021.8.26.0540
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269168/2021 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 20611798 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 3331/21/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 3331/2021 - 1º Distrito Policial de Mauá, 2269168 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLAUDECIR ALVES FERREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

CLAUDEIR FRANCISCO RODRIGUES e CLAUDECIR ALVES FERREIRA foram denunciados por incursão no inciso IV do parágrafo 4.º do art. 155 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 12h20min, na Avenida Joaquim Chavasco, 71 - Jardim Mauá, nesta cidade de Mauá, os denunciados, em concurso de agentes, mediante escalada, tentaram subtrair, em proveito comum, bens, em prejuízo da Prefeitura Municipal de Mauá, não se consumando por

circunstâncias alheias à vontade da dupla.

Recebida a denúncia, o réu Claudeir foi citado (fl. 201) e apresentou resposta à acusação.

O processo foi suspenso em relação ao réu Claudecir, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls.189-90).

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se o réu Claudeir.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, excluindo-se a qualificadora da escalada, enquanto a Defesa requer a absolvição ante a atipicidade ou insignificância da conduta ou, ao menos, o reconhecimento da tentativa, a fixação da pena no patamar mínimo, com incidência da atenuante da confissão, sob regime penitenciário aberto, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A acusação procede em parte.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls. 07-10), auto de exibição e apreensão (fl. 13), além da prova oral colhida.

O réu, em solo policial, permaneceu em silêncio (fl.06). Em juízo, manifestou-se (mídia digital).

O guarda municipal Edson, na fase administrativa (fl.03), historiou que: (sic) "na data de 02/10/2021, por volta de 12:20, foi acionado via Cecom para comparecer até a Avenida Joaquim Chavasco, 71 - Jardim Mauá - CEP: 09340-190 Mauá - SP (UBS Jardim Mauá) para verificar informação de que dois indivíduos tinham acabado de pular o muro do referido estabelecimento, ocasião em que imediatamente procedeu até o local; que no local, ao entrar na UBS, logrou abordar os indivíduos que ora sabe chamar Claudecir Alves Ferreira e Claudeir Francisco Rodrigues já em seu interior, de posse de diversas ferramentas, sendo certo que, indagados, ambos confessaram que tinham entrado no local para efetuar a subtração de itens que poderiam ser revendidos posteriormente em 'ferro velho', como torneiras e outros acessórios de metais, todavia, não lograram subtrair nenhum até o momento pois foram abordados pelos guardas; que ambos relataram que utilizariam as ferramentas, ora apreendidas, para facilitar a subtração dos objetos e que entraram no local após pular um muro, utilizando-se do apoio de um banco de concreto do ponto de ônibus, sem maiores dificuldades".

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Marcelo (fl.04).

Em juízo, o guarda civil Marcelo disse que foram avisados, via rádio, que indivíduos tinham pulado o muro do posto de saúde no Jardim Mauá. Chegaram rápido no local, conseguiram abrir o portão e abordar os réus antes que eles arrombassem a porta. Estes quiseram correr, mas não tiveram chance. Os réus pularam o muro, que é uma grade baixa, com auxílio do banco do ponto de ônibus e estavam com ferramentas. Abordaram os réus antes que entrassem no posto de saúde, como se fosse no quintal da UBS. Disseram que furtariam torneira, algo interessante (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de guardas municipais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa

simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial, o que também se aplica aos guardas civis municipais. Em caso análogo:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Assim, diante dos depoimentos dos guardas municipais, afasta-se a tese defensiva de meros atos preparatórios impuníveis e atipicidade da conduta. Os réus pularam o muro e foram surpreendidos com ferramentas dentro do terreno do posto de saúde, praticando, assim, atos executórios e expondo o bem jurídico protegido pela norma penal a perigo real, apenas não se consumando o crime pela intervenção dos guardas civis.

Neste sentido o e. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO (ART. 155, § 1º E § 4º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓD. PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO REVELA A PRÁTICA APENAS DE ATOS PREPARATÓRIOS E DE COGITAÇÃO. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI. ACUSADO SURPREENDIDO NO INTERIOR DA GARAGEM DA RESIDÊNCIA. TENTATIVA DE FUGA. PRÁTICA DE ATO INEQUIVOCAMENTE EXECUTÓRIO. PROPÓSITO DE ASSENHORAMENTO DE COISA ALHEIA MÓVEL EVIDENCIADO. TENTATIVA DE FURTO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO PRESERVADA. Se o agente foi surpreendido no interior da garagem da residência da vítima, sendo imobilizado quando tentava transpor o muro da propriedade, não se pode falar apenas em cogitação ou atos preparatórios, porquanto praticou atos que expôs a risco relevante e concreto o bem jurídico protegido, dando assim início à execução do crime patrimonial que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse contexto, se a versão do réu no sentido de que buscava apenas se proteger de uma perseguição estiver completamente dissociada da realidade probatória, não há como afastar o animus furandi, à luz do disposto no art. 156, caput, do Código de Processo Penal. (...) (TJSC, AP Nº 5012037-76.2020.8.24.0018, REL. DES. SIDNEY ELOY DALABRIDA, j. 15 de abril de 2021).

Ainda, o c. Superior Tribunal de Justiça:

(...) Quando o agente penetra no verbo nuclear, sem dúvida, pratica atos executórios. No entanto, comportamentos periféricos que, conforme o plano do autor, uma vez externados, evidenciam o risco relevante ao bem jurídico tutelado também caracterizam início da execução do crime. (...) (REsp 1252770/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 26/03/2015).

Descabida, ainda, a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Na lição de NELSON HUNGRIA "a coisa subtraída deve representar para o dono, senão um valor reduzível a dinheiro, pelo menos uma utilidade (valor de uso), seja qual for, de modo que possa ser considerada como integrante de seu patrimônio. O valor mínimo da coisa pode ser uma minorante do furto (art. 155, §2º), mas não uma discriminante. Somente não se podem considerar objeto de furto as coisas de valor juridicamente irrelevante (ex. alfinete, um palito, uma flor vulgar)" (in Comentário ao Código Penal", vol. VII, 4ª Ed., pág. 23, Rio de Janeiro, Forense, 1980).

Nesta linha:

Sobre o tema, oportuno trazer à baila a brilhante ponderação do ilustre

Desembargador Dr. Corrêa de Moraes: "(A) Alegadamente construída com propósitos liberais, a tese do 'crime de bagatela' nada mais representa, em última análise, que a 'camuflagem teórica de uma distorção ideológica': seria axiologicamente inócuo e até mesmo 'politicamente correto' subtrair coisa alheia móvel, porque a propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que, 'de lege lata', é um absurdo e, 'de lege ferenda', uma leviandade. Para o caso em que 'é de pequeno valor a coisa furtada', o legislador reservou as mercês do § 2º do art. 155. Nada além disso. (B) A 'Teoria da Bagatela' é, em última análise, a 'bagatela da teoria', pura extravagância teórica, idealizada para assegurar a impunidade do infrator. Para a mão que ofende, a lesão é sempre de 'bagatela'. Mas é sempre dolorosa para o rosto que a suporta. Para a mão que furta, a lesão patrimonial é sempre de bagatela. Mas é sempre aflitiva para o bolso desfalcado. Nesse relativismo pendular, fico com o sujeito passivo. É necessário ter bem presente no espírito que a reprovação/punição da conduta em exame (e de comportamentos análogos) tem conteúdo ético, que abstrai do peso econômico da coisa subtraída. O que se reprova/pune, com total independência do valor circunstancial da coisa sobre a qual recai a ação é o desvalor, a negatividade axiológica da própria conduta. O preceito subjacente à previsão repressiva do art. 155 é 'não furtarás' nem isto nem aquilo, nada importando se isto vale muito e aquilo vale pouco. Em tais condições, o diminuto peso econômico da coisa não pode ser levado à categoria de causa excludente da ilicitude". (TJSP, APR 0002038-58.2017.8.26.0270, Rel. Walter da Silva, j. 30.05.19).

No mais, a qualificadora pelo concurso de agentes afasta o princípio da insignificância, conforme jurisprudência pacificada no e. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância" (HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016)." (AgRg no AgResp 1.272.319, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.10.18).

A qualificadora do concurso de pessoas está devidamente comprovada pela prova oral colhida. Todavia, como bem observado pelo Ministério Público, não configurada a qualificadora da escalada diante do depoimento do guarda municipal que afirmou que a grade é baixa, além da ausência de laudo pericial, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Portanto, comprovado o delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Passo à dosagem das penas.

Atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes (certidão de fl. 42 – proc. 1762-21.2016), perfazendo 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa.

Sobre a possibilidade de utilização de uma das condenações, transitada em julgado, como maus antecedentes:

"Admite-se a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem". (STJ. Resp 1946490/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

"(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma." (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

"Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena." (HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

"Apelação. Roubo. (...) Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Bases fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, por ocasião do mau antecedente. Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão. Presença de duas condenações pretéritas definitivas, valoradas, cada qual, como circunstância judicial negativa e agravante não configura dupla valoração. Defensoria Pública que insiste na ocorrência de bis in idem, valendo-se de julgado proferido no remoto ano de 2012. Alegação superada, inclusive, pelos Tribunais Superiores. Penas mantidas em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1501829-67.2020.8.26.0348; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021).

Na segunda etapa, a reprimenda merece acréscimo de 2/3, diante da multirreincidência específica do réu (cert fls. 42-7 - procs. 2064-56.2016, 2155-15.2017, 3877-49.2015, 4504-53.2015, 8341-19.2015, 1500843-56.2019), perfazendo 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 18 dias-multa.

A multirreincidência específica justifica aumento em patamar maior, frente ao maior o desvalor da conduta. Em cado análogo:

"APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA - Recurso defensivo. Devidamente demonstradas materialidade e autoria delitivas, não havendo sequer insurgência a esse respeito pela defesa. Redução da pena - Impossibilidade. Maus antecedentes. Ausência de 'bis in idem'. Condenações distintas a configurar Maus antecedentes e reincidência. Fatos geradores diversos. Possível a majoração de 2/3 pela multirreincidência específica, posto que coerentes com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena - Precedentes. - Fixação de regime inicial menos gravoso - Descabimento - réu multirreincidente específico. Circunstância que atesta maior reprovabilidade concreta da conduta do apelante e demonstra que a fixação de regime inicial mais brando não seria suficiente para atender aos requisitos de suficiência e necessidade para a prevenção e reprovação. Ausência de 'bis in idem' na utilização da recidiva para exacerbar a pena, na segunda etapa da dosimetria, e, posteriormente, para fixação do regime prisional - Recurso desprovido (TJSP, Apelação Criminal nº 1503100-83.2021.8.26.0540, Rel. Des. CAMILO LÉLLIS, j. 20 de maio de 2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - Sentença condenatória - Tese defensiva referente à tentativa que não comporta acolhida - Réu que foi detido após inversão da posse, já distante da residência da vítima - Teoria da apprehensio ou amotio - Recurso do MP para refazimento da dosimetria penal - Admissibilidade - Multirreincidência (específica, frisa-se) que veda a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea - Réu que registra pelo menos sete condenações definitivas por crimes idênticos, dentre as quais cinco são aptas a caracterizar a reincidência - Penas elevadas em 2/3 na fase intermediária - Regime prisional alterado para o fechado, considerando as suas condições pessoais (extensa biografia criminal) e as circunstâncias do caso concreto. Apelação do MP provida. Apelação defensiva não provida." (TJSP; Apelação Criminal 1500249-28.2021.8.26.0619; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª

Câmara de Direito Criminal; Foro de Taquaritinga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/09/2021; Data de Registro: 17/09/2021).

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante dentro do terreno do posto de saúde, com ferramentas, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisum sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recurso de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do

convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechados mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"Descabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da precisa fundamentação exarada pelo d. Juiz sentenciante: "Justifica-se, na segunda etapa, a não incidência da atenuante da confissão, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão, não espontânea, de quem foi preso em flagrante na posse do objeto subtraído, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisor sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ".(TJSP, Apelação Criminal nº 1502274-57.2021.8.26.0540, Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, j. 23 de maio de 2022).

"(...) Não era o caso, outrossim, do reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto tenha ela sido parcial (negou o apelante o emprego de arma de fogo), bem como por ser ela refratária à prisão em flagrante. Como bem destacou o MM. Juízo a quo, no decisor, "(...) Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após desembarcar do veículo roubado, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos." (fls. 148). De mais a mais, ainda que fosse possível seu reconhecimento, nenhuma redução seria feita, pois, como adiantado, já foram as penas bases mantidas no mínimo legal." (TJSP; Apelação Criminal 1502696-32.2021.8.26.0540; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 06/07/2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravos regimentais no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravo regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser

reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

Ainda que assim não fosse o caso, não haveria repercussão na pena, pois a confissão seria compensada com apenas uma das reincidências.

Na fase final, em razão da tentativa, observado o iter criminis percorrido -o réu já tinha pulado o muro e estava dentro do terreno do posto de saúde- procede-se a diminuição da pena em 1/3, atingindo-se 02 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão e 12 dias-multa.

O valor do dia multa é o unitário mínimo.

O réu, multirreincidente específico, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado. Pelos mesmos motivos não incide o disposto no art. 44 do Código Penal. Neste sentido o e. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORANTE DO FURTO NOTURNO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE NA MODALIDADE QUALIFICADORA DO CRIME DE FURTO. LEGALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES E RECIDIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. No que se refere ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 anos de reclusão, os maus antecedentes do acusado implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ. (STJ, HC 559086, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.03.20).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR o réu CLAUDEIR FRANCISCO RODRIGUES, qualificado nos autos, a cumprir pena de 02 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 12 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no inciso IV do parágrafo 4º do art. 155 do Código Penal.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito

(assinado eletronicamente)

Mauá, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA